

1510416-36.2019.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76

- Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico

ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato

da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510416-36.2019.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510416-36.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 2070651/2019 - 56º Distrito Policial - Vila

Alpina, 1315/2019 - 56º Distrito Policial - Vila Alpina

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE FELBER

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 111/20

VISTOS.

FELIPE FELBER, qualificado nos autos, porque consta que em data incerta, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em conjunto e unidade de propósitos com pessoa não identificada, remeteu, para posterior entrega a consumo alheio, via "sedex", para o interior do CDP Vila Independência, situado na Av. Doutor Francisco Mesquita, 5.98 gramas da substância entorpecente denominada "cocaína" e 8,8 gramas da substância tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha" substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica. A denúncia foi recebida à fl. 178.

Defesa Preliminar apresentada à fl. 228.

Durante a instrução processual, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, duas testemunhas de acusação, e o réu foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia, por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pelo redutor máximo previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, a pena no mínimo, regime mais brando e direito de recurso em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, dando conta das 4 tampas de tubo de pasta de dente contendo maconha, de uma tampa de tubo de pasta de dente contendo cocaína, encontrados em poder do réu.

Em complementação, o laudo químico toxicológico de fls. 55/57, atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para tetrahydrocannabinol e cocaína.

A autoria também é inconteste.

De fato, os argumentos de sua defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e as provas diretas contra ele derivadas, em especial, pelas testemunhas inquiridas e declarações do próprio increpado que nada de exculpatório trouxe aos autos.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o réu declarou que não foi minha mãe que mandou esse SEDEX. Ela conheceu essa mulher na cadeia que pediu o nome dela e ela deu. Ela fez amizade com essa mulher e disse que ia me ajudar. Essa droga não era para mim, eu estava pegando só a higiene porque minha mãe estava desempregada. Eu não sabia que tinha droga dentro de uma pasta. Eu fui preso em um tráfico de drogas. Estou trabalhando com eventos.

A mãe do réu, Marcia Pereira dos Santos, ouvida como informante, declarou em Juízo que meu filho foi preso e eu sempre levava jumbo para ele. Eu nunca mandei SEDEX, porque nem sei como faz isso, e também porque SEDEX é caríssimo. Então quando cheguei, um dos agentes me chamou em uma salinha e me mostrou um sedex que tinha sido encaminhado para meu filho, com meu nome. Eu não encaminhei esses sedex. Lembro que uma vez, uma senhora de idade, me pediu meu nome e meus documentos para mandar um sedex para o filho dela, mas ela mandou em meu nome. O sedex estava endereçado para meu filho, mas eu nunca mandei sedex para ele. Eu fiz amizade com essa senhora no presídio, porque ela me disse que o filho dela estava preso também, e como foi a primeira vez que meu filho foi preso, acabei fazendo amizade com ela. Eu fiquei com pena dela, porque ela disse que a carteirinha dela ainda não tinha ficado pronta.

Ocorre porém que tanto as negativas do réu como as tentativas de sua genitora em isentá-lo de tão grave acusação restaram isoladas e em absoluto não convenceram. Ora, como se vê dos autos, o sedex contendo as drogas foi encaminhado para o réu, e a tese dele que referida encomenda não lhe pertencia não encontra respaldo em nenhuma prova produzida nos autos.

Não se pode crer que o réu fosse acusado da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivesse ele, efetiva participação nos fatos. Ainda mais quando as partes são desconhecidas e não existe um indício sequer a revelar que a prova acusatória pudesse ter por finalidade única prejudicar o réu ou mesmo acusa-lo falsamente.

Os agentes penitenciários, Luciano Adelino dos Santos e Igor Juliano Chaves de Souza, declararam em juízo de forma firme, segura e em uma só voz que trabalhávamos como agentes penitenciários no CDP. Nós recebemos uma correspondência via SEDEX, enviada para o réu. Quando ele veio receber a correspondência e nós abrimos o pacote, havia tubos de pasta de dente no interior do qual estavam escondidas as drogas. Nós apresentamos a ele o que foi encontrado e o encaminhamos para o setor

próprio. Como remetente constava a mãe do réu. Em razão do tempo, e da quantidade de presos que trata, o agente penitenciário Luciano não foi capaz de se recordar do réu, mas o agente penitenciário Igor o reconheceu em audiência. As drogas estavam camufladas dentro da tampa da pasta.

Os agentes narraram com segurança e precisão como se deu a prisão do acusado, relatando todos os detalhes, desde a revista de correspondência enviada aos detentos, o encontro das substâncias entorpecentes remetidas pelo denunciado e comparsa, tudo isso na frente do réu, até final prisão.

Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

Neste sentido: "Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial." (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94).

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Tóxico. Depoimento prestado por policial. Prova firme e coerente. Apreensão em fiscalização de Trânsito e de rotina. Circunstância que justifica o não arrolamento de testemunha alheia ao quadro policial. Recurso não provido". (Apelação criminal. 126.697-3, rel. Des. Álvaro Cury. RJTJESP n. 138/451).

Além disso, os depoimentos das agentes foram tranquilos, harmoniosos e revelaram sincronia lógica. Narraram a situação com firmeza, descrevendo as diligências sem qualquer mácula ou eiva de vício a contaminar a prova. Não houve contradição na parte substancial do que disseram na fase policial e em Juízo, de maneira que seus depoimentos devem ser valorados como qualquer outro elemento de prova.

A fala das testemunhas mostrou-se coerente, repita-se e firme desde a fase inquisitiva, narrando com clareza o discorrer dos fatos. Em que pesem os argumentos da esforçada defesa, alegando em síntese que não lograram êxito na prova da traficância, vejo nos autos que todas as circunstâncias apontam em sentido contrário.

Neste contexto, em vista da grande quantidade de drogas que estavam em poder do réu, a forma como estavam acondicionadas, a própria dinâmica dos fatos, visto que o réu estava preso em estabelecimento prisional, e ainda o relato seguro e firme por parte dos agentes, resta inexoravelmente comprovado que mantinha substância tóxica para consumo e entrega a terceiros.

Nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercancia, pudesse vir a inocentar a acusada da imputação descrita na denúncia. E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como de conteúdo múltiplo ou variado, preencheu a ré um dos núcleos do tipo denunciado, sendo pois, impossível a absolvição pretendida pela defesa. Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não ter o agente, sido surpreendido no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de acondicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 - Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de mercancia - Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canellas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

Destarte, não evidenciou-se qualquer situação que pudesse excluir o crime ou isentar o réu da pena.

O acusado praticou os fatos no interior de estabelecimento prisional. Presente, pois, a causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, atento dolo normal à espécie. Verifico que o réu ostenta uma condenação por outro tráfico, conforme

certidão de fls. 174, mas são posteriores aos fatos, de maneira que fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Presente a agravante descrita na denúncia, motivo pelo qual, nesta segunda fase, aumento a pena no mínimo previsto, 1/6, perfazendo, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. A despeito da agravante, vejo que a quantidade de drogas não é expressiva e o réu era primário ao tempo do crime, de sorte que aplico a redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em 1/3, para, não havendo outras circunstâncias, tornar definitiva a pena em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias multa.

O valor do dia multa é o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar FELIPE FELBER, como incurso nas penas do artigo 33, § 4º e artigo 40, inciso III, da Lei nº11.343/06, a cumprir, em regime inicialmente aberto, a pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias multa.

Na hipótese específica destes autos, o regime aberto se justifica tendo em vista que o réu era primário, foi solto no curso do processo e compareceu a todos os atos para os quais foi chamada. Além disso, encontra-se trabalhando, sendo que fazê-lo retornar aos sistemas carcerários revela medida excessivamente drástica como forma de repressão e retribuição.

De outro giro, não é possível a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantêm repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovedor deve ser segregado do convívio social.

Não se pode perder de vista ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apreço. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram. No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever: "Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: "inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum)."

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos, pode ser aplicada e reconhecida.

Oficie-se à autoridade policial, oportunamente, para incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de março de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA